

0003227-94.2016.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003227-94.2016.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003227-94.2016.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 341/2016 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Autor:

Justiça Pública

Réu

FERNANDO HENRIQUE ROSSI e GABRIEL RUIZ MARTINS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

FERNANDO HENRIQUE ROSSI (fls. 204) foi denunciado como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e GABRIEL RUIZ MARTINS (fls. 212) foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 01/02).

Isso porque, segundo consta, no dia 28 de julho de 2016, por volta de 10h20min, na Rua Ederaldo Antunes de Oliveira, nº 285, bairro dos Machados, zona rural, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, o acusado Fernando portava munição, de uso permitido, sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (um) cartucho integro de calibre 20, conforme auto de exibição e apreensão.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o acusado Gabriel mantinha em sua residência, um vaso contendo onze plantas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: PM Paulo Sérgio Pereira (fls. 51) e o PM Fábio Silva Paduim (fls. 50).

Recebida a denúncia (fls. 231), os acusados foram citados pessoalmente (fls. 255 e 277) e apresentaram defesa prévia (fls. 285/289 e 301/302), por defensor(a)(s)

nomeado(a)(s) (fls. 290 e 294), negando a prática do delito, pedindo absolvição e arrolando as seguintes testemunhas de Defesa: Rodrigo Leandro dos Santos. O recebimento da denúncia foi ratificado, sendo realizada audiência de instrução. As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 14, 50, 51, 68, 78, 145, 154, 197/198 e 205/206), auto(s) de exibição e apreensão (fls. 10/13) e laudo(s) pericial (is) (fls. 16/17, 41/42 112/114 e 116/118, 120/121 e 122/125).

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Segundo apurado, os policiais militares estavam em patrulhamento no bairro dos Machados, nesta cidade de José Bonifácio, quando avistaram FERNANDO HENRIQUE ROSSI, que fugiu ao vir os policiais, pulando o muro dos fundos, dispensando uma sacola contendo uma luva que tinha em seu interior uma munição intacta calibre 20, marca CBC, espoletas e bisnaga com pólvora e vela branca fragmentada.

Posteriormente, os milicianos adentraram no interior da residência, onde encontraram Nauane Iara da Silva Ribeiro, que afirmou que a residência era de GABRIEL RUIZ MARTINS.

No interior da residência foi encontrado um vaso contendo onze plantas de maconha. Auto de exibição e apreensão a fls. 05/06.

Foram apreendidos:

- Em poder de Fernando Henrique Rossi: uma luva de lã, cor branca; uma embalagem contendo pólvora parcialmente utilizada; três pedaços de chumbo; um cartucho íntegro de calibre 20; 33 espoletas, modelo "Tupan", 6, 45, nº 56, com embalagem metálica; dois pedaços de vela de cera; 01 recipiente de plástico azul usado como vaso e 8 plantas vivas aparentando ser maconha

O exame de munição de arma de fogo e de peças relacionadas concluiu o seguinte:

- Um cartucho de munição de arma longa, carregado, intacto, da marca CVC, do calibre 20, de metal e plástico amarelos, com carga de múltiplos balins de chumbo com 4,5 milímetros de diâmetro, que estava apto para a realização de disparo, confirmando-se, portanto, as suas eficácia e potencialidade lesiva
- 33 espoletas próprias para carga/recarga de cartuchos de munição, com 6,45 milímetros de diâmetro, que estavam dispostas em uma embalagem metálica circular, com as gravações: "100 espoletas 6,45 Tupan nº 58 CBC", que demonstraram serem eficazes para o fim ao qual se destinam
- três balotes de chumbo de formato cilíndrico, com 18 milímetros de comprimento, 14 milímetros de diâmetro e 19,5 gramas de peso médio, próprios para carga/recarga de cartuchos de munição de arma longa
- 18,4 gramas de pólvora que estava disposta em uma embalagem de papel contendo entre outras as inscrições: "Explosivos, Fogos de artifício, marca Guarani", que demonstrou ser eficaz para o fim ao qual se destina

O laudo de exame químico-toxicológico apontou resultado positivo para tetrahidrocanabinol - THC nas amostras colhidas de um recipiente plástico de caro azul utilizado como vaso, contendo terra e 11 plantas medindo entre 5,0 cm e 13,0 cm de comprimento, e apresentando 0,83 gramas de peso seco total, constituídas por raiz, caule, folhas compostas por folíolos de bordos serrilhados e frutos.

A testemunha PM Paulo Sérgio Pereira narrou que o local dos fatos é conhecido pela prática de tráfico e, durante patrulhamento, o acusado correu para os fundos da residência e dispensou uma sacola branca e pulou o muro. O cartucho foi dispensado na fuga. Fernando não morava na residência. A casa não possuía muros e tinha acesso pelos fundos. A esposa de Fernando atendeu e autorizou a entrada. Ela disse que ali também morava um amigo deles, que é o acusado Gabriel. Acharam um pé de maconha num vaso no interior da residência. Fernando é conhecido dos meios policiais, mas

Gabriel não. Não se recorda de objetos pessoais no local.

A testemunha PM Fábio Silva Paduim relatou que se aproximaram de uma casa e viram Fernando correr para os fundos da residência, que não era dele. Fernando dispensou uma sacola, mas o depoente não se lembra o objeto. Não conseguiram abordá-lo e não tinha nenhum proprietário presente no momento. Gabriel não estava presente. No quintal, aos fundos, havia um vaso com uma planta de maconha.

Houve desistência da testemunha Rodrigo Leandro dos Santos.

O interrogatório do acusado Fernando restou prejudicado pela revelia.

Em seu interrogatório, o acusado Gabriel negou a acusação, afirmando que estava viajando e só passava os finais de semana na casa. Deixou o acusado e sua esposa morarem na residência por uns dias até arrumarem nova moradia, mas a droga não é sua e apenas é usuário de maconha.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que os delitos estão efetivamente caracterizados, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

O local dos fatos era conhecido pela prática de tráfico e, durante patrulhamento, o acusado Fernando correu para os fundos da residência e dispensou uma sacola branca, onde foi encontrada a munição apreendida, cuja eficácia e potencialidade lesivas restaram demonstradas pelo laudo pericial. A esposa de Fernando autorizou a entrada dos policiais, que encontraram um vaso com as plantas de maconha também apreendidas. Embora a casa fosse desprovida de muros, ali morava o acusado Gabriel, usuário de drogas, como por ele próprio admitido. Diante disso e como as plantas já estavam crescidas, a tese do acusado, no sentido de que estava viajando e desconhecia a origem delas, carece de credibilidade e verossimilhança.

Vale dizer que o simples fato de as testemunhas policiais militares, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios

A esse respeito, a jurisprudência é remansosa:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os policiais pretendessem incriminar os acusados falsamente, ou seja, não haveria razão para supor que eles teriam faltado com a verdade.

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que é incabível presumir a culpa apenas porque a droga e munições foram encontradas dentro do imóvel. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelos acusados precisaria ser verossímil e não foi. Na verdade, a tese de Defesa pressupõe que a conduta dos agentes assumiu conotação abusiva ou que alguém desconhecido queria prejudicá-los, mas não há razão concreta e idônea que a sustente, pelos motivos já expostos.

Portanto, as propriedades das munições e das plantas de maconha devem ser atribuídas aos acusados Fernando e Gabriel respectivamente.

Logo, as condutas não estão acobertadas por causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, restando bem caracterizada a prática dos delitos.

Não obstante, cabe uma ressalva quanto à capitulação (art. 383 do CPP), uma vez que o cultivo de plantas que constituam matéria-prima para a preparação de drogas caracteriza tráfico na forma do art. 33, §1º, III, da Lei 11.343/06.

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

Prevalece na jurisprudência que, por serem circunstâncias preponderantes e devido à vedação ao bis in idem, a natureza e a quantidade de entorpecente devem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e só podem ser usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser

necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

7. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n.

666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa

ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

O delito de tráfico é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é punido com pena de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

A pena de multa é calculada em dias-multa, sendo, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP), segundo o critério trifásico previsto no art. 68 do CP.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

I- Quanto a Fernando

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui condenações transitadas em julgado para a Defesa em 13/11/2018 (data do fato: 07/10/2016), 10/02/2022 (data do fato: 17/05/2015), 16/01/2008 (data do fato: 24/06/2005), 15/01/2007 (data do fato: 26/07/2004), com extinção da pena em 27/02/2012, e 23/05/2019 (data do fato: 08/12/2018) (fls. 403/408).

Conforme o entendimento jurisprudencial, as condenações por fatos posteriores ao descrito na denúncia não caracterizam antecedentes e condenações antigas podem ser valoradas negativamente porque os antecedentes não se sujeitam ao prazo depurador de 5 anos aplicável à reincidência (art. 64, I, do CP)

A jurisprudência atual desta Corte, sedimentada no Enunciado de Súmula 444, veda às instâncias inferiores valorar negativamente a pena-base em função de inquéritos ou processos em curso, sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio da presunção de não culpa. Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa. (HC 443.678/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. (HC 433.543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da

pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

Assim, a primeira condenação em negrito deve ser utilizada para caracterizar a reincidência, que é circunstância agravante, a ser valorada na segunda fase (Súmula 241 do STJ), enquanto a segunda deve ser valorada negativamente como circunstância judicial desfavorável.

Ainda de acordo com a jurisprudência, "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Diante disso, as demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima) não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificarem a exasperação da pena-base.

Conforme a jurisprudência, em regra, é razoável exasperar a pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, porém, é possível aplicar fração superior para a valoração de um único vetor, se preponderante:

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (AgRg no HC 666.280/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Assim, pela presença de antecedente(s), mostra-se proporcional ao caso concreto exasperar a pena em 1/6, o que resulta em: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pelo antecedente mencionado, motivo pelo qual a pena deve ser exasperada em 1/6, o que resulta em: 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Logo, torno definitiva a pena em: 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, b, do Código Penal).

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem à suspensão condicional da pena, uma vez que, embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e a pena seja inferior a 4 anos, o acusado possui as condenações criminais descritas, sendo reincidente, de modo que a concessão dos benefícios não seria suficiente ou socialmente recomendável (arts. 44, 59 e 77 do CP).

II- Quanto a Gabriel

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado é primário (fls. 402).

Diante disso, as demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como

grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima) não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificarem a exasperação da pena-base.

Por sua vez, a natureza e quantidade de droga encontrada apenas corroboram a caracterização do tráfico, não justificando a exasperação da pena-base.

Assim, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa, considerando que o acusado é nascido em 30/12/1997, que, contudo, não repercute na dosimetria, uma vez que a pena se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Consequentemente, a pena não se altera.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Presente a causa de diminuição de 1/6 a 2/3 prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que o acusado é primário e inexistem indicativos de seu envolvimento em organização criminosa ou atividades criminosas, não bastando a quantidade de droga isoladamente para afastar o redutor: "Esta Corte vem decidindo que a quantidade de entorpecentes apreendidos, isoladamente não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova, para atestar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa" (AgRg no AREsp 1636928/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Assim, inexistindo razões para maior rigor, cabe aplicar a maior fração de diminuição, ou seja, 2/3, o que resulta em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Logo, torno definitiva a pena em: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pelo montante, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do Código Penal).

O acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a pena não supera 4 anos, ele é primário e não cometeu o crime com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 44 do CP).

Na condenação superior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP).

Considerando que a sanção penal deve cumprir função pedagógica e social, cabível a aplicação de duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução (arts. 43, I e IV; 45 e 46 do CP; e art. 483 das NSCGJ).

Fica prejudicada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar:

I- FERNANDO HENRIQUE ROSSI à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03; e

II- GABRIEL RUIZ MARTINS à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, §§1º, III, e 4º, da Lei 11.343/06. Com fundamento nos arts. 44, §2º; 43, I e IV; 45 e 46 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade a ele aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, à entidade pública ou privada com



destinação social, a ser definida pelo juízo da execução e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução.

Como efeito da condenação, declaro a perda das munições apreendidas, por constituírem instrumentos do crime, cujo porte ou detenção constituem fato ilícito (art. 91 do CP e art. 25 da Lei 10.826/03). Por não mais interessarem ao processo, determino o seu encaminhamento ao Comando do Exército e autorizo sua destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Por não mais interessar ao processo, autorizo a destruição do entorpecente apreendido (art. 72 da Lei 11.343/06 e art. 524-A das NSCGJ). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Custas pelos réus, observada a gratuidade de justiça.

Os acusados respondem ao processo em liberdade, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar. Portanto, eles fazem jus ao direito de recorrer em liberdade, salvo se por outros motivos devam ficar presos (art. 387, §§1º e 2º, do CPP).

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão quanto a Fernando e, após seu cumprimento, a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedidas as guias, elas deverão ser encaminhadas ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspensão" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, determino a restituição das luvas e fragmentos de vela apreendido ao acusado Fernando, por, apesar de se tratar de instrumentos do crime, não consistir em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (art. 91, II, a, do CP e art. 118 do CPP, interpretado a contrario sensu). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Saem os presentes intimados.

José Bonifacio, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA